

1500047-77.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira
Comarca: Piracicaba
Foro: Foro de Piracicaba
Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... MAYCON - que de longa data se dedica ao tráfico de drogas (Ostenta condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) - trazia consigo porções de crack e cocaína para comercialização no endereço acima descrito, área urbana em que reiteradamente são registradas ocorrências policiais relacionadas ao tráfico de entorpecentes.
Estava em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500047-77.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2004484/2022 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 22293855 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 53/22/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2004484 - 02º D.P. PIRACICABA, 53/22/922 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAYCON FERREIRA DE MEDEIROS FERMINO

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 26 dias do mês de maio de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Rafael Augusto Pressutto e o(a) Defensor(a), Dr. Eduardo Henrique Ciappina. Apresentados o(a)(s) acusado(a)(s) MAYCON FERREIRA DE MEDEIROS FERMINO, e as testemunhas arroladas pela acusação: Gilmar Pereira da Costa e Geuffrey Santos de Carvalho.

Ausentes as testemunhas arroladas pela defesa: Alexandre Alves, Ilma Cavalcanti dos Santos, Nicoli Oliveira Soares, Marcos Ricardo Fermino e Elisangela de Medeiros. Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito

cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s) acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) da acusação (Gilmar e Geuffrey), pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado(a)(s) o(a)(s) réu(ré)(s). Pelo defensor foi dito que desiste da oitiva das testemunhas por si arroladas.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

Homologo a desistência da Defesa em relação às testemunhas Alexandre Alves, Ilma Cavalcanti dos Santos, Nicoli Oliveira Soares, Marcos Ricardo Fermino e Elisângela de Medeiros.

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, MAYCON FERREIRA DE MEDEIROS FERMINO está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Isso porque, no dia 05 de janeiro de 2022, por volta de 19h00min, na Rua Alfredo José de Castro Neves, n.º 20, Cecap, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, trazia consigo, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 82 (oitenta e dois) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 20,5g (vinte gramas e cinco decigramas), e 52 (cinquenta e dois) invólucros em plástico e papel alumínio contendo crack, substância derivada da cocaína, com peso líquido de 5,2g (cinco gramas e dois decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Feito regularmente processado. A denúncia foi ofertada em 25 de janeiro de 2022 (fls. 97/99). Após a notificação (fls. 107), sobreveio a defesa prévia (fls. 108/117). Mantido o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 129/134).

A ação penal procede.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo auto de exibição e apreensão às fls. 31, boletim de ocorrência de fls. 08/10, laudos periciais toxicológicos de fls. 33/35 e 125/127, foto às fls. 36 e prova oral.

A autoria é certa na pessoa de MAYCON.

Segundo consta da denúncia, MAYCON - que de longa data se dedica ao tráfico de drogas (Ostenta condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) - trazia consigo porções de crack e cocaína para comercialização no endereço acima descrito, área urbana em que reiteradamente são registradas ocorrências policiais relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

Estava em plena atividade criminosa - se posicionava estrategicamente na via pública com as drogas no bolso para pronta entrega aos usuários - quando avistou policiais militares e tentou sair furtivamente para evitar a abordagem.

O comportamento evasivo, dadas as condições de local e horário, foi percebido pelos agentes, que imediatamente realizaram a abordagem. No bolso da bermuda de MAYCON foram encontrados 82 (oitenta e dois) eppendorfs de cocaína e 52 (cinquenta e duas) pedras de crack (foto fls. 36).

Durante o procedimento policial, o denunciado se desvencilhou dos agentes e correu em fuga até ser detido em uma avenida do bairro.

Informalmente, confessou a prática delitiva. Na delegacia, porém, ficou silente (fls. 05/06).

Em exame pericial, foi constatada a presença de cocaína nas substâncias apreendidas (auto de exibição fls. 31 e laudo pericial de constatação fls. 33/35).

Diante das circunstâncias, notadamente as condições pessoais, a tentativa de fuga, o local amplamente conhecido como ponto de venda de drogas, a apreensão de cocaína e crack em quantidade e forma incompatíveis com a mera alegação de uso pessoal, é certo que o denunciado trazia consigo os entorpecentes com a finalidade de comércio ilícito.

Da prova na fase policial:

O policial militar Gilmar Pereira da Costa apresentou sua narrativa na delegacia:

"É Policial Militar e exerce suas funções na Força Tática; nesta noite, por volta

das 19h, estava na companhia Sd PM Carvalho e Cb PM Antonelli, em patrulhamento pelo bairro Cecap, mais especificamente na Rua Fernando Monteiro, esquina com a Rua Alfredo de Castro Neves, local já conhecido nos meios policiais como sendo utilizado por indivíduos na prática de tráfico de entorpecentes, onde avistaram um indivíduo parado na via, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, agiu de maneira estranha, tentando esconder-se por entre os arbustos, sendo ele imediatamente abordado e identificado como sendo Maycon Ferreira de Medeiros Fermino; com ele foi apreendido, no bolso da lateral direita de sua bermuda, oitenta e dois tubos eppendorff contendo cocaína, além de cinquenta e dois invólucros de crack, embalados de maneira típica a propiciar a venda à terceiros; indagado preliminarmente, ainda no local dos fatos, informou que estava, de fato, vendendo drogas naquele local para complementar sua renda; assim, face o exposto, deu voz de prisão a Maycon Ferreira de Medeiros Fermino, ocasião em que ele conseguiu desvencilhar-se e tentou fuga pelas ruas do bairro, sendo então acompanhado e contido na Av. Gustavo Adolfo Franco Bueno, altura do numeral 416, naquele mesmo bairro, motivo este que ensejou o uso de algemas; não conhecia o indiciado anteriormente." (fls. 03).

O policial militar Geuffrey Santos de Carvalho narrou de forma semelhante:

"Trabalha como Policial Militar, em exercício na Cia de Força Tática; nesta noite, por volta das 19h, realizavam patrulhamento pelo bairro Cecap, mais especificamente na Rua Fernando Monteiro, esquina com a Rua Alfredo de Castro Neves, um local já conhecido nos meios policiais como sendo utilizado por indivíduos que lá permanecem vendendo drogas; naquele local, visualizaram um indivíduo parado na via, tendo ele iniciado movimentação atípica ao perceber que a viatura se aproximava, tentando esconder-se por entre os arbustos; foi ele abordado e identificado como sendo Maycon Ferreira de Medeiros Fermino, com quem foi apreendido, no bolso da lateral direita de sua bermuda, oitenta e dois tubos eppendorff contendo cocaína e cinquenta e dois invólucros de crack; quando inquirido, Maycon prontamente confessou que estava vendendo drogas naquele local para complementar sua renda; o indivíduo recebeu voz de prisão em flagrante e, então, evadiu-se do local da abordagem, sendo imediatamente acompanhado e contido na Av. Gustavo Adolfo Franco Bueno, altura do numeral 416, naquele mesmo bairro; foi necessário o uso de algemas para evitar nova tentativa de fuga; não conhecia o indiciado anteriormente." (fls. 04).

No interrogatório policial, MAYCON ficou silente (fls. 05/06).

Da prova na fase judicial:

O policial militar Gilmar Pereira da Costa disse que, no dia dos fatos, em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico, avistaram o acusado em atitude suspeita, tentando se esconder entre arbustos. Realizada a abordagem, apreenderam 82 porções de cocaína e 52 de crack. O réu, então, confessou o tráfico e empreendeu fuga, sendo, posteriormente, perseguido e abordado, depois de alguns quarteirões. O local se trata de uma praça em que há arbustos. Os entorpecentes apreendidos estavam no bolso da bermuda do acusado. O acusado não possuía dinheiro e inclusive disse que acabava de assumir o "turno de serviço" no tráfico. Durante a fuga, um dos policiais saiu ao seu encalço a pé, enquanto ele o outro policial prosseguiram na viatura.

O policial militar Geuffrey Santos de Carvalho prestou depoimento no mesmo sentido de seu colega de farda.

Interrogado em juízo, o acusado negou a prática do delito, apresentando versão fantasiosa e inverossímil.

Da caracterização do crime de tráfico de drogas:

Ao cabo da instrução, restaram comprovados os elementos informativos colhidos produzidos no procedimento investigatório, bem delineando a prática delitiva contida no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A condenação é de rigor, senão vejamos.

MAYCON se posicionava em local amplamente conhecido como ponto de venda de drogas quando tentou se furtar da visualização de policiais militares que se aproximavam. Diante das circunstâncias, foi abordado e revistado: no bolso de sua bermuda foram encontrados 82 (oitenta e dois) eppendorfs de cocaína e 52 (cinquenta e duas) pedras de crack (foto fls. 36).

A palavra dos policiais foi harmônica e coerente nos detalhes da abordagem, dinâmica do encontro da droga e condução do autuado. Ademais, não há qualquer elemento a infirmar o depoimento policial, já que os agentes sequer conheciam MAYCON e inexistia qualquer elemento a indicar que tenham atuado com mero e gratuito propósito de prejudicá-lo. Nada há, portanto, a macular a credibilidade dos testemunhos policiais. Nesse sentido: “A só condição de policiais militares não os torna suspeitos. Seus depoimentos são colhidos mediante o compromisso de dizer a verdade, como qualquer outra testemunha e suas afirmações são sopesadas em conjunto com as demais provas” (Apelação nº 0001180-13.2016.8.26.0286. 4ª Câmara de Direito Criminal. Voto 39686. Des. Rel. Euvaldo Chaib. Julgado em 12.09.2017).

Assim, a quantidade, natureza e forma de acondicionamento dos entorpecentes, a tentativa de fuga, as condições pessoais e o local da apreensão não deixam qualquer dúvida da posse das drogas com finalidade de comércio ilícito.

Portanto, comprovados os fatos narrados na denúncia, a responsabilização penal é medida que se impõe.

Da dosimetria

Na primeira fase, cumpre destacar que MAYCON é portador de maus antecedentes: condenado por tráfico de drogas nos autos n.º 0016877-64.2016.8.26.0451 - fls. 48: t.j. em 04.09.2018, execução nº 006697-36.2017.8.26.0521. Diante disso, pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal.

Na segunda fase, há de se considerar a reincidência específica: condenado pelo crime de associação para o tráfico nos autos n.º 0018015-03.2015.8.26.0451 (fls. 48/49: t.j. em 17.09.2019, execução n.º 0015113-79.2019.8.26.0502).

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem reconhecidas. As condições pessoais de MAYCON não autorizam o reconhecimento da causa de diminuição contida no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas – réu portador de maus antecedentes e reincidente específico.

Outrossim, das mesmas razões emergem a necessidade de imposição do regime prisional inicial o fechado. Mesmo diante das penas corporais que já suportou – cumpriu pena em regime rigoroso e, quando da prisão pelos fatos ora processados, cumpria pena em regime aberto – MAYCON não foi desestimulado à prática de crimes. Diante desse cenário, é necessária a intervenção estatal firme e rigorosa com a finalidade de reprovar e desestimular a continuidade das práticas delituosas. Assim, a fixação de regime prisional diverso do fechado à MAYCON remanesceria insuficiente à prevenção e reprovação do crime.

Ante o exposto, requeiro seja julgada procedente a presente ação penal, condenando-se MAYCON FERREIRA DE MEDEIROS FERMINO nos termos da inicial.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juiza, MAYCON FERREIRA DE MEDEIROS FERMINO, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, através de seu procurador ao final subscrito, vem respeitosamente a presença de V. Exa, na forma do art. 55, § 1º, da Lei Federal nº. 11.343/2006 c/c art. 394, § 2º, da Legislação Adjetiva Penal, tempestivamente, no decêndio legal, oferecer sua

ALEGAÇÕES FINAIS

(com pedido de “liberdade provisória”)

Quanto à pretensão condenatória ostentada em desfavor do acusado, consoante abaixo delineado.

1 – SÍNTESE DOS FATOS

O Acusado foi denunciado pelo Ministério Público Estadual, em 24 de janeiro de 2022, como incurso no tipo penal previsto no art. 33 caput da Lei Federal nº. 11.343/2006, pela suposta prática da conduta delituosa abaixo descrita. Segundo a peça acusatória, na tarde do dia 05 de janeiro de 2022, por volta das 19:00h, integrantes da Polícia Militar abordaram o acusado em conhecido ponto de venda de drogas com 82 (oitenta e dois) eppendorfs contendo cocaína e 52 (cinquenta e dois) invólucros em plástico e papel alumínio contendo crack, em seu bolso, praticando mercância dos ilícitos. Consta também da peça acusatória que o acusado tentou empreender fuga, sendo capturado logo em seguida. Extrai-se ainda que houve confissão informal do acusado durante a abordagem, porém

em sede policial manteve-se silente.

2 - DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA SEM A PRESENÇA DO RÉU

Sendo o Brasil signatário do Pacto de San José da Costa Rica, pacto este firmado na Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 e que foi devidamente absorvida pela Constituição Federal Brasileira de 1988, é cristalinamente clara a necessidade de, diante de qualquer prisão, a apresentação do acusado à autoridade judiciária o que não ocorreu no caso em tela, constituindo verdadeira esquizofrenia jurídica a continuidade do presente processo nos moldes em que se apresenta como uma "gestante sem feto", senão vejamos:

"EMENTA: 1. "Habeas corpus". Audiência de custódia (ou de apresentação) não realizada. A realização da audiência de custódia (ou de apresentação) como direito subjetivo da pessoa submetida a prisão cautelar. Direito fundamental reconhecido pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Artigo 7, n. 5) e pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 9, n. 3). (...) A ausência da realização da audiência de custódia (ou de apresentação), tendo em vista a sua essencialidade e considerando os fins a que se destina, qualifica-se como causa geradora da ilegalidade da própria prisão em flagrante, com o consequente relaxamento da privação cautelar da liberdade individual da pessoa sob poder do Estado. Magistério da doutrina: AURY LOPES JR. ("Direito Processual Penal", p. 674/680, item n. 4.7, 17ª ed., 2020, Saraiva), GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ ("Processo Penal", p. 1.206, item n. 18.2.5.5, 8ª ed., 2020, RT), RENATO BRASILEIRO DE LIMA ("Manual de Processo Penal", p. 1.024/1.025, 8ª ed., 2020, JusPODIVM) e RENATO MARCÃO ("Curso de Processo Penal", p. 778/786, item n. 2.12, 6ª ed., 2020, Saraiva)." (STF MC em HC 186421 - SC, MIN. CELSO DE MELO. 17/07/2020)"(Grifo nosso)

Portanto, a audiência de custódia é procedimento obrigatório, pela qual toda pessoa presa em flagrante deverá ser apresentada em até 24 horas da prisão à autoridade judicial competente e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão.

O STF, ao julgar a ADPF 347, antes ainda da vigência do Pacote Anticrime, já entendia pela obrigatoriedade dos juízes e tribunais em realizar a audiência de custódia:

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão. (ADPF 347 MC, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 18-02-2016 PUBLIC 19-02-2016) (Grifo nosso)

Trata-se de um meio idôneo para evitar prisões arbitrárias e ilegais. Dessa forma, a ausência da realização da audiência de custódia, qualifica-se como nítida ilegalidade da própria prisão em flagrante, com o consequente relaxamento da privação cautelar. Ocorre Excelência, que conforme há de comprovar por provas testemunhais em momento oportuno, o ora custodiado foi espancado pelas autoridades policiais e portanto, era mister que fosse devidamente apresentado ao juiz da audiência de custódia.

Em vista disso, cristalina justiça que seja anulada a prisão, sendo emitido o respectivo alvará de soltura, para que o mesmo possa responder em liberdade.

Ainda...

Da ilegalidade da prisão de ofício

Na referida decisão, o Ministro Celso de Melo destacou ainda, sobre a impossibilidade de de decretação de ofício de prisão preventiva, independente da situação:

"(...) 2. Impossibilidade, de outro lado, da decretação "ex officio" de prisão preventiva em qualquer situação (em juízo ou no curso de investigação penal), inclusive no contexto de audiência de custódia (ou de apresentação), sem que se registre, mesmo na hipótese da conversão a que se refere o art. 310, II, do CPP, prévia, necessária e indispensável provocação do Ministério Público ou da autoridade policial. Recente inovação legislativa introduzida pela Lei nº 13.964/2019 ("Lei Anticrime"), que alterou os arts. 282, § 2º, e 311, do Código de

Processo Penal, suprimindo ao magistrado a possibilidade de ordenar, "sponte sua", a imposição de prisão preventiva. Não realização, no caso, da audiência de custódia (ou de apresentação). Conversão, de ofício, mesmo assim, da prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva. Impossibilidade de tal ato, seja em face da ilegalidade dessa decisão, seja, ainda, em razão de ofensa a um direito básico - o de realização da audiência de custódia - assegurado a qualquer pessoa pelo ordenamento doméstico e por convenções internacionais de direitos humanos. Medida cautelar concedida "ex officio". (...) (Grifo nosso)

- A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, § 2º, e 311, também do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência." (STF MC em HC 186421 - SC, MIN. CELSO DE MELO. 17/07/2020)

Diante da vigência da Lei 13.964/19, que instituiu o pacote anticrime, o magistrado não pode mais decretar prisão de ofício, sendo cabível o seu decreto somente a requerimento do Ministério Público, do assistente de acusação ou por representação da autoridade policial.

Cabe destacar que a Lei 13.964/19 excluiu expressamente o termo "de ofício" previsto na redação antiga do dispositivo legal do Art. 311 CPP, passando a prever expressamente, no Art. 282, a possibilidade da prisão cautelar somente a pedido das partes, in verbis:

"Art. 282. (...) § 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público." (Grifo nosso)

Dessa forma, duas importantes prerrogativas do preso, além de positivadas pelo pacote anticrime, passaram a ser validadas por decisão do Ministro do STF. Portanto Excelência, desde já se requer a anulação da prisão preventiva do acusado, devendo este ser colocado em imediata liberdade pois direito de defesa fundamental foi fatalmente cerceado, podendo este responder em liberdade as acusações até o deslinde do processo, pois possui trabalho e residência fixa

3 - DO PEDIDO DE "LIBERDADE PROVISÓRIA"

De regra tem entendido alguns Tribunais que, quando se tratar da hipótese de crime de tráfico de drogas, como o é a hipótese absurda ora imputada ao Acusado, a liberdade provisória há de ser negada, sob o ângulo do art. 44, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas) e, mais, para alguns, sob o manto do art. 5º, inc. XLIII, da Carta Magna.

Um grande equívoco que, ademais, vem sendo reiteradamente alterado este raciocínio. Vejamos, a propósito, considerações acerca da impertinência daquelas decisões denegatórias da Liberdade Provisória, aos crimes ora em debate.

Saliente-se, primeiramente, que o Acusado é primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa, o que, como provas, acostamos aos autos, ofuscando, pois, quaisquer dos parâmetros da segregação cautelar prevista no art. 312 da Legislação Adjetiva Penal.(docs. 01/05)

3.1. Regras de hermenêutica

- Conflito aparente de normas (antinomia)

- Um enfoque sob o ângulo do "Critério Cronológico

Segundo as lições consagradas do ilustre e renomado jurista italiano Norberto Bobbio:

" A situação de normas incompatíveis entre si é uma dificuldade tradicional frente a qual se encontraram os juristas de todos os tempos, e teve uma denominação própria: antinomia.

(. . .)

Definimos antinomia como aquela situação na qual são colocadas em existência duas normas, das quais uma obriga e a outra permite, ou uma proíbe e a outra permite o mesmo comportamento."(Bobbio, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 4ª Ed.

Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 1994. Pág. 81-86)"

Dentro do tema de antinomia de regras, com mais precisão sob o ensejo do critério da cronologia de regras, no tocante ao crime de tráfico de entorpecentes, já sob a vigência da Lei nº 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), existia comando legal de sorte a não permitir a concessão de liberdade provisória (art. 2º, inc. II), a qual fora reiterada pela Lei nº. 11.343/06 (Lei de Drogas), em seu art. 44. Tal vedação fora suprimida, entretantes, pela Lei nº. 11.464, de 29 de março de 2007, que alterou o citado dispositivo da Lei nº. 8.072/90, deixando de existir a proibição da liberdade provisória nos crimes hediondos e equiparados, mas tão-somente tratando da fiança.

É consabido que uma lei posterior, de mesma hierarquia, revoga (expressa ou tacitamente) a lei anterior, naquilo que for colidente.

Novamente colhemos as lições de Norberto Bobbio, quando, sob o trato de colisão de leis no tempo, professa que:

" As regras fundamentais para a solução de antinomias são três: a) o critério cronológico; b) o critério hierárquico; c) o critério da especialidade;

O critério cronológico, chamado também de Lex posterior, é aquele com base no qual, entre duas normas incompatíveis, prevalece a norma posterior: Lex posterior derogat priori. Esse critério não necessita de comentário particular. Existe uma regra geral do Direito em que a vontade posterior revoga a precedente, e que de dois atos de vontade da mesma pessoa vale o último no tempo. Imagine-se a Lei como a expressão da vontade do legislador e não haverá dificuldade em justificar a regra. A regra contrária obstaría o progresso jurídico, a adaptação gradual do Direito às exigências sociais. Pensemos, por absurdo, nas consequências que derivariam da regra que prescrevesse ater-se à norma precedente. Além disso, presume-se que o legislador não queria fazer coisa inútil e sem finalidade: se devesse prevalecer a norma precedente, a lei sucessiva seria um ato inútil e sem finalidade. "(ob. e aut., cits., pág. 92-93).

Na hipótese em estudo, como se percebe, uma lei geral posterior, in casu a Lei nº 11.464/2007, que trata dos crimes hediondos e equiparados, revogou uma lei anterior especial que trata do crime hediondo de tráfico de drogas (art. 44, da Lei 11.343/2006).

Vejamos, mais, as colocações de Norberto Avena, quando, citando o pensamento do Professor Luis Flávio Gomes, destaca que:

"1ª Posição: A Lei 11.464/2007, ao excluir dos crimes hediondos e equiparados a vedação à liberdade provisória, sendo posterior à nova Lei de Drogas, revogou, taticamente, o art. 44 desta lei que proibia o benefício aos crimes lá relacionados. Adepto deste entendimento, Luis Flávio Gomes utiliza o critério da cronologia das leis no tempo para concluir no sentido da prevalência da normatização inserta à Lei dos Crimes Hediondos. Refere, pois:

'A Lei dos Crimes Hediondos (Lei 8.072/1990), em sua redação original, proibia, nesses crimes e nos equiparados, a concessão de liberdade provisória (essa é a liberdade que acontece logo após a prisão em flagrante, quando injustificada a prisão cautelar do sujeito). Tráfico de drogas sempre foi considerado crime equiparado (desde 1990). A mesma proibição foi reiterada na nova Lei de Drogas (Lei 11.343/2006), em seu art. 44. A partir de 08.10.2006 (data em que entrou em vigor esta última lei), a proibição achava-se presente tanto na lei geral (Lei de Crimes Hediondos) como na lei especial (Lei de Drogas). Esse cenário foi completamente alterado com o advento da Lei 11.464/2007 (vigente desde 29.03.07), que suprimiu a proibição da liberdade provisória nos crimes hediondos e equiparados (previa então no art. 2º, inciso II, da Lei 8.072/1990). Como se vê, houve uma sucessão de leis processuais materiais. O princípio regente (da posterioridade), destarte, é o seguinte: a lei posterior revoga a lei anterior (essa revogação, como sabemos, pode ser expressa ou tácita; no caso, a Lei 11.464/2007, que é geral, derogou parte do art. 44 da Lei 11.343/2006, que é especial). Em outras palavras, desapareceu do citado art. 44 a proibição da liberdade provisória, porque a lei nova revogou (derrogou) a antiga, seja porque com ela é incompatível, seja porque cuidou inteiramente da matéria. "(Avena, Norberto Cláudio Pâncaro. Processo Penal: Esquematizado. 4ª Ed. São Paulo: Método, 2012. Pág. 975)

Na mesma sorte de entendimento, vejamos o que leciona Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar:

" a) Crimes hediondos e assemelhados (tráfico, tortura e terrorismo): estas infrações, como já relatado, não admitem a prestação de fiança (art. 5º, inc. XLIII, CF). Contudo, por força da Lei nº. 11.464/2007, alterando o art. 2º, inc. II, da Lei nº. 8.072/1990, passaram a admitir a liberdade provisória sem fiança.

O interessante é que o crime de tortura, que é assemelhado a hediondo, já comportava liberdade provisória sem fiança, em razão do art. 1º, § 6º da Lei nº 9.455/1997.

Já quanto ao tráfico de drogas, a questão exige bom senso. É que a Lei nº 11.343/2006, lei especial que disciplina o tráfico e condutas assemelhadas, no caput do art. 44 veda a fiança e a liberdade provisória sem fiança a tais infrações. Ora, mesmo sendo lei especial, acreditamos que houve revogação tácita com o advento da Lei nº 11.464/2007 alterando a lei de crimes hediondos. Se todos os hediondos e assemelhados comportam liberdade provisória sem fiança, o tráfico não foge à regra. A razoabilidade justifica a medida. Afinal, onde há a mesma razão, deve haver o mesmo direito. "(Távora, Nestor; Alencar, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 7ª Ed. Bahia: JusPodvm, 2012. Pág. 652)

Seguindo todas estas óticas supra evidenciadas, vejamos os seguintes julgados: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE, CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO, COM BASE NA VEDAÇÃO LEGAL (ART. 44 DA LEI Nº 11.343/2006) E NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. (Grifo nosso)

I. Dispõe o art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal que será concedido habeas corpus "sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder", não cabendo a sua utilização como substituto de recurso ordinário, tampouco de Recurso Especial, nem como sucedâneo da revisão criminal. II. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, recentemente, os HCs 109.956/PR (DJe de 11/09/2012) e 104.045/RJ (DJe de 06/09/2012), considerou inadequado o writ, para substituir recurso ordinário constitucional, em Habeas corpus julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, reafirmando que o remédio constitucional não pode ser utilizado, indistintamente, sob pena de banalizar o seu precípuo objetivo e desordenar a lógica recursal. III. O Superior Tribunal de Justiça também tem reforçado a necessidade de se cumprir as regras do sistema recursal vigente, sob pena de torná-lo inócuo e desnecessário (art. 105, II, a, e III, da CF/88), considerando o âmbito restrito do habeas corpus, previsto constitucionalmente, no que diz respeito ao STJ, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, nas hipóteses do art. 105, I, c, e II, a, da Carta Magna. IV. Nada impede, contudo, que, na hipótese de habeas corpus substitutivo de recursos especial e ordinário ou de revisão criminal - que não merece conhecimento -, seja concedido habeas corpus, de ofício, em caso de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica. V. Na hipótese, constata-se o constrangimento ilegal, na medida em que o benefício da liberdade provisória foi negado, convertida a prisão em flagrante em preventiva, com base, unicamente, na gravidade abstrata do delito e na vedação do art. 44 da Lei nº 11.343/2006, o que, de acordo com a atual jurisprudência do STJ, não se admite. Precedentes. VI. A vedação legal à concessão da liberdade provisória aos processados pelos delitos de tráfico de drogas, prevista no art. 44 da Lei nº 11.343/2006, foi, recentemente, declarada inconstitucional, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (HC 104.339/SP), incidentalmente. Informativo 665, do STF. VII. Habeas corpus não conhecido. VIII. Concedida a ordem, de ofício, para revogar a prisão preventiva, deferindo-se, ao paciente, o benefício da liberdade

provisória, sem prejuízo da imposição, pelo Juízo de 1º Grau, de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. (STJ - HC 251.502; Proc. 2012/0169966-1; SP; Sexta Turma; Relª Minª Assusete Magalhães; Julg. 04/12/2012; DJE 18/12/2012)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ART. 44 DA LEI N. 11.343/2006. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL A QUO COMPLEMENTAR OS ARGUMENTOS DO DECRETO DE PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. POUCA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (2,71 G DE CRACK E 6,97 G DE MACONHA).

1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o Juízo a quo não trouxe nenhum elemento concreto que demonstrasse o preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, mas fez uso de ilações abstratas acerca da gravidade do delito, além de fundamentar a decisão na vedação legal à liberdade provisória prevista na Lei n. 11.343/2006. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 104.339/SP, declarou a inconstitucionalidade da expressão "e liberdade provisória", constante do art. 44 da Lei n. 11.343/2006, conforme noticiado no Informativo de Jurisprudência n. 665, de 7 a 11/5/2012, daquela Corte. 4. Novas razões aduzidas pelo Tribunal de origem para justificar a custódia cautelar, por ocasião do julgamento do writ originário, não suprem a falta de fundamentação observada no Decreto prisional. 5. Ordem concedida para deferir ao paciente a liberdade provisória, salvo prisão por outro motivo ou superveniência de fatos novos e concretos que autorizem a sua decretação. (STJ - HC 248.776; Proc. 2012/0148049-1; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 09/10/2012; DJE 30/11/2012)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE. 1,92 G DE MASSA LÍQUIDA DE COCAÍNA E 0,62 G DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ART. 44 DA LEI N. 11.343/2006. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso ordinário previsto nos arts. 105, II, a, da Constituição Federal e 30 da Lei n. 8.038/1990, consoante atual entendimento adotado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, que não têm mais admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais. 2. No julgamento do HC n. 104.339/SP, em 10/5/2012, conforme noticiado no Informativo de Jurisprudência n. 665/STF, de 7 a 11/5/2012, o Supremo Tribunal Federal declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade de parte do art. 44 da Lei n. 11.343/2006, que proibia a concessão de liberdade provisória nos crimes de tráfico de entorpecentes. 3. As instâncias ordinárias não indicaram fatos concretos aptos a justificar a segregação cautelar da paciente, estando as decisões fundamentadas simplesmente na gravidade abstrata do crime, o que configura nítido constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para deferir a liberdade provisória à paciente. (STJ - HC 252.435; Proc. 2012/0178212-1; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 07/11/2012; DJE 26/11/2012)

3.2. Prisão em flagrante é prisão cautelar

- O Acusado não ostenta quaisquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP

- Inescusável o deferimento do pedido de liberdade provisória

De outro bordo, como nas linhas inaugurais deste tópico foram levantadas e demonstradas, o Acusado não ostenta quaisquer das hipóteses situadas no art. 312 da Legislação Adjetiva Penal, as quais, neste ponto, poderiam inviabilizar o pleito de liberdade provisória.

Como se vê, o Acusado, antes negando a prática dos delitos que lhes restaram imputados pelo Parquet, demonstrou, nesta peça, acima, que é réu primário e de bons antecedentes, comprovando, mais, possuir residência fixa e ocupação lícita. Neste diapasão, mesmo em se tratando de crime de tráfico ilícito de drogas, à luz dos ditames contrários previstos no art. 44 da Lei de Drogas, o Acusado faz jus à

liberdade provisória, sem a implicação de pagamento de fiança. Não há nos autos, outrossim, quaisquer motivos que implique na decretação preventiva do Acusado.

Vejamos, a propósito, julgados neste tocante:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO QUE CONVERTE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES. SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. (Grifo nosso)

1. A simples referência à natureza do crime de tráfico de drogas ou à sua gravidade abstrata, fazendo apenas menção à "natureza do fato e das circunstâncias em que ele ocorreu", e à condição pessoal dos pacientes, apontando abstratamente a necessidade de assegurar a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da Lei Penal, sem apontamentos concretos das razões que se chegou a tal convencimento, não são suficientes para estear a prisão com o objetivo de assegurar a aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal; 2. Estando a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva ausente de fundamentação idônea, mas não demonstrando a contento os pacientes que preenchem os requisitos para auferirem a liberdade provisória, impõe-se a fixação de medidas cautelares alternativas à segregação provisória, devendo ser valorada sob o prisma da proporcionalidade, razoabilidade e adequabilidade. 3. Ordem concedida. (TJRO - HC 0011654-78.2012.8.22.0000; Rel^a Des^a Marialva Henriques Daldegan; Julg. 09/01/2013; DJERO 11/01/2013; Pág. 64)

HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS APREENSÃO DE 17,33 GRAMAS DE COCAÍNA. PLEITO VISANDO O DEFERIMENTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA ADMISSIBILIDADE. PACIENTE QUE É PRIMÁRIO, POSSUIDOR DE BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO LÍCITO. (Grifo nosso)

Necessidade da custódia para garantia da ordem pública não demonstrada Gravidade do crime que, por si só, não pode ensejar a manutenção da prisão cautelar Ausência de violência ou grave ameaça à pessoa no crime praticado Possibilidade da imposição das medidas cautelares. Concessão parcial da ordem, para que seja deferida a liberdade provisória em favor do paciente, com a imposição das medidas cautelares previstas nos incisos I e V, do artigo 319 do CPP Extensão dos benefícios a corré Jane Keli Cristina Roque. (TJSP - HC 0233440-86.2012.8.26.0000; Ac. 6423125; Orlândia; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Borges Pereira; Julg. 18/12/2012; DJESP 11/01/2013)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSISTÊNCIA DAS ASSERTIVAS. ANÁLISE DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA À LUZ DO DISPOSTO NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECLARAÇÃO, PELO TRIBUNAL PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACERCA DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 44 DA LEI N. 11.343/06, NA PARTE QUE VEDAVA A LIBERDADE PROVISÓRIA AOS ACUSADOS DA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO. AFRONTA AO DISPOSTO NO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE SUSTENTADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. DECISÃO QUE NÃO INDICA ELEMENTOS FÁTICOS E CONCRETOS QUE DEMONSTREM A INDISPENSABILIDADE DA CLAUSURA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. (Grifo nosso)

O plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei n. 11.343/2006, na parte que vedava a liberdade provisória aos acusados pela prática do crime de tráfico de substância entorpecente, razão pela qual revela-se necessária a análise do pedido de liberdade dos acusados pela prática do delito de tráfico de drogas à luz dos requisitos do art. 312 do código de processo penal. A decisão que mantém a custódia cautelar deve ser fundamentada em quaisquer das hipóteses previstas no art. 312 do código de processo penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da Lei penal, conjugadas com a novel redação do art. 313 do mesmo CODEX, demonstradas por meio de elementos concretos, tendo em vista que apenas o embasamento genérico acerca da gravidade abstrata do crime e do risco à ordem pública, não são motivos suficientes para a imposição da custódia cautelar, sob pena de violar o princípio da presunção da não culpabilidade e o inciso IX do

art. 93 da Constituição Federal. Ordem concedida. (TJMT - HC 133345/2012; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva; Julg. 12/12/2012; DJMT 10/01/2013; Pág. 102)

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO

As provas trazidas aos autos claramente ratificam o réu encontrava-se apenas no local errado e na hora errada, estando provado que este não concorreu de forma alguma para a prática do crime constante na denúncia.

O artigo 386, V, do Código de Processo Penal é categórico ao afirmar que a hipótese constante dos autos é caso de absolvição, senão vejamos:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...) Omissis

V - não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

A hipótese trazida no texto legal acima invocado, retrata-se a evidência da existência de um fato criminoso, contudo, no caso em tela não restou cabalmente demonstrada que o denunciado é o autor do fato delituoso.

Conforme consta dos autos, o local no qual fora encontrado o denunciado é conhecido por ser local de traficância, assim podem existir coautores responsabilizados ou não.

A realidade construída através das provas colhidas, quais sejam, expressa merecimento por parte do acusado de obter a absolvição, uma vez não se tendo construído um universo sólido de evidências contra sua pessoa.

Sendo assim, os elementos probatórios carreados nos autos não demonstram ter o acusado, de qualquer forma, concorrido para a prática da infração penal, devendo desde logo ser absolvido.

Insta salientar ainda que não é possível afirmar com certeza que o denunciado era proprietário ou que estava realizando a venda das drogas, ou ainda, que tenha contribuído para o tráfico de drogas da região, assim como a fala dos policiais ouvidos não fora capaz de evidenciar a traficância atribuída ao denunciado, uma vez que, repise-se o denunciado não encontrado praticando a traficância.

Sobre o tema o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, já se manifestou:

APELAÇÃO CRIME- TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06)-PLEITO ABSOLUTÓRIO - PROVAS INSUFICIENTES PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONVINCENTES PARA A CONDENAÇÃO - O ÔNUS DA PROVA CABE AO TITULAR DA AÇÃO PENAL, NOS TERMOS DO ART. 156 DO CPP - SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA -SENTENÇA REFORMADA - .RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO (TJPR - 3ª C.Criminal - 0046732-83.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: José Cichocki Neto - J. 15.02.2019)

Assim, considerando que não há nos autos elementos de convicção suficientes que liguem o denunciado ao crime de tráfico de drogas, a medida que se impõe é a sua absolvição, nos moldes do artigo 386, V do Código de Processo Penal.

DA APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO

Caso o entendimento de Vossa Excelência seja diverso, postula-se pela aplicação do artigo 386, VII do Código de Processo Penal, senão vejamos:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...) Omissis

VII - não existir prova suficiente para a condenação. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008).

Conforme é cediço, é dever da acusação provar os fatos narrados na denúncia, contudo, no caso em tela, a acusação não se desincumbiu do ônus inalterável de provar os fatos narrados na denúncia, uma vez que, não restou cabalmente demonstrado que o denunciado estava traficando.

Desta feita, se a acusação se propõe a provar um fato e, ao término da instrução, existe dúvida razoável sobre sua existência, não pode declará-lo como provado, devendo tal evento ser considerado inexistente e não provado, aplicando-se a sentença absolutória do inciso VII.

Sobre o tema a jurisprudência já se manifestou, senão vejamos:

Apelação criminal 01. Condenação. Artigo 35, cabeça (1º fato), artigo 33, cabeça (2º fato) e artigo 33, § 1º, inciso II (3º fato), todos da Lei 11.343/06, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (4º fato). Absolvição do delito de furto (5º fato). Insurgência do órgão ministerial. Pleito condenatório. Impossibilidade.

Inexistência de certeza. Dúvida quanto à autoria delitiva. Apelo conhecido, porém, desprovido. 1. Tendo em vista não ter sido demonstrada, de maneira indene de dúvidas, a existência da certeza necessária à prolação do decreto condenatório, a manutenção da sentença absolutória em relação ao crime de furto é medida que se impõe, em homenagem ao princípio do *in dubio pro reo* Apelação Criminal 02.

Condenação. Artigo 35, cabeça (1º fato), artigo 33, cabeça (2º fato) e artigo 33, § 1º, inciso II (3º fato), todos da Lei 11.343/06, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (4º fato). Absolvição do crime de associação para o tráfico. Não acolhimento.

Estabilidade e permanência evidenciadas. Prescindibilidade de prova da efetiva corrupção para caracterização do delito tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Reforma do processo de dosagem da pena. Aplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado aos delitos tipificados no artigo 33 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Incompatibilidade com crime do artigo 35 do mesmo diploma normativo. Modificação do regime inicial de cumprimento da pena em razão da detração. Descabimento. Instituto que não se presta a modificar o regime já fixado pelo juízo sentenciante. Substituição da pena. Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos legais (artigo 44, do Código Penal). Apelo conhecido, porém, não provido. 1. A existência de denúncias anônimas aliada a prova oral colhida no decorrer da instrução criminal evidencia todas as elementares do tipo penal insculpido no artigo 35, da Lei de Drogas, tornando inviável o acolhimento do pleito absolutório. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, inclusive (tema 221), que o delito do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente prescinde de prova da efetiva corrupção do menor. A exacerbação da reprimenda em razão da natureza e quantidade da droga apreendida é suficiente à elevação da pena básica em um oitavo (1/8), em consonância com o que determina o artigo 42, da Lei 11.343/2006. Não se presta o instituto da detração à alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado na instância 0 não preenchimento dos requisitos a quo. estabelecidos no artigo 44, do Código Penal obsta o acolhimento da pretensão de ver substituída a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. (TJPR - 5ª C.Criminal - 0000979-76.2017.8.16.0120 - Nova Fátima - Rel.: Rogério Etzel - J. 28.02.2019)

Destarte, diante da insuficiência probatória, posto que a acusação não conseguiu demonstrar que os fatos efetivamente ocorreram para que pudessem imputar a prática delituosa ao denunciado, não conseguindo, conseqüentemente, demonstrar que fora a conduta do denunciado que causou a lesão ao bem juridicamente protegido, que ressaí dos autos, a pretensão punitiva merece ser julgada improcedente.

DOS POSSÍVEIS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA PENA

Embora nítida a tese da absolvição por não estar comprovado o crime de tráfico, convém demonstrar outras situações que devem ser observadas por Vossa Excelência. A Lei de Drogas combate veementemente o tráfico de entorpecentes, mas há que se observar determinados critérios para a fixação da pena, tais como, a quantidade de droga apreendida, as suas condições pessoais, dentre outros.

Excelência, o réu é trabalhador e arrimo de família, com proposta de emprego garantida e possui residência fixa, e ajuda a cuidar de sua mãe que está muito debilitada.

Assim, ao denunciado deve ser deferida a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme garantida pela lei penal; e ainda, que sua pena seja fixada no mínimo legal pelas circunstâncias já elencadas.

Excelência, ninguém nasce mal, ninguém nasce bandido, tudo é uma questão de oportunidade, o jovem da favela também quer um tênis novo, uma roupa nova. O réu por exemplo, é fruto de lar desfeito, de uma mãe dependente química, o réu tem vários irmãos muitos deles vivendo em abrigos, vez que, a mãe perdeu o pátrio poder.

Excelência, o réu infelizmente é mais uma vítima do sistema falido que vivemos, um

sistema que pune e não recupera, assim, manter o réu preso ou condená-lo a uma pena de reclusão é retirar dessa vítima, sim vítima, do sistema o direito de sonhar e acreditar que sim é possível ser exceção da regra.

Na busca do caráter ressocializador da pena, a justiça deve trabalhar para aplicar aquilo que se coaduna com a realidade social.

Hoje, infelizmente, nosso Sistema Prisional é cercado de incertezas sobre a verdadeira função de ressocialização dos indivíduos que lá são mantidos, onde em muitos casos se trata de verdadeira "escola do crime".

Com base no princípio da presunção de inocência, previsto na nossa Constituição Federal em seu art. 5º, inciso LVII, requer o denunciado que responda ao processo em liberdade, até o trânsito em julgado, pois as circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado (art. 282, inciso II, CPP) lhe são favoráveis pelo fato de não haver reincidência e sua conduta social não ser em nenhum momento questionada.

DA DOSIMETRIA DA PENA

O artigo 59 do Código Penal, traz os critérios de fixação da pena, senão vejamos:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

Conforme se extrai da leitura do texto de lei acima, cabe ao magistrado analisar os critérios para a fixação da pena

Tais circunstâncias, denominadas judiciais, por balizarem uma atuação jurisdicional fundada num exercício discricionário, é, como dito, permitir a aplicação de penas